

1501272-06.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) - grifou-se.

Na hipótese, dos relatos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501272-06.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501272-06.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DAVI CLEBER FERREIRA DE MELO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

KAYO CALADO DA SILVA, ERICK HENRIQUE VIEIRA SILVA, FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA foram processados como incurso no art. 288 do CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, na forma do art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B, § 2º, do ECA, todos na forma do art. 69 do CP, porque em data incerta, até o dia 12/5/2022, por volta das 19h50, na Rua Francisco Biasi, Jardim Corcovado, Campo Limpo Paulista/SP, em conjunto com Davi Cleber Ferreira de Melo, falecido, e com o adolescente Allysson Matias Lourenço dos Santos, associaram-se para o fim específico de praticar crimes, notadamente roubos com emprego de arma de fogo. Ainda, aos 12/5/2022, por volta das 19h50, na Rua Francisco Biasi, Jardim Corcovado, Campo Limpo Paulista/SP, os acusados, em conjunto com Davi Cleber Ferreira de Melo, falecido, e com o adolescente Allysson Matias Lourenço dos Santos, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Honda/XRE 190 SE, de cor prata e placa FPT7F97 - Campo Limpo Paulista/SP, pertencente à vítima Flávio Alexandre Pavam.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corromperam o adolescente Allysson Matias Lourenço dos Santos, nascido em 28/1/2005, com ele praticando os crimes acima elencados.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 226/229, em 6/6/2022, com decretação da prisão preventiva de todos os acusados à exceção de Fernando Pereira dos Santos.

Respostas à acusação juntadas às fls. 334/335 (Kayo Calado da Silva), 338/340 (Josevaldo Ferreira da Silva), 353/360 (Erick Henrique Vieira da Silva) e 454/469 (Fernando Pereira dos Santos).

Ratificou-se o recebimento às fls. 470/471, com designação de audiência de instrução, realizada em 11/10/2022, oportunidade em que ouvidos a vítima, testemunhas e os acusados, à exceção de Josevaldo Ferreira da Silva, que embora citado (fl. 382), não compareceu ao ato, tendo sido decretada sua revelia.

O Ministério Público apresentou memoriais às fls. 541/577, pugnando pela procedência da pretensão acusatória.

Erick Henrique Vieira da Silva sustentou sua absolvição pelos seguintes fundamentos: a) foi reconhecido pelo corréu em procedimento que não observou os termos do art. 226 do CPP; b) o corréu Kayo, confesso, retratou-se parcialmente do depoimento prestado na fase policial, o qual foi realizado mediante grave ameaça, tendo isentado o acusado de qualquer participação; c) os testemunhos não comprovam seu envolvimento no delito; d) com relação às provas obtidas por Facebook, o acusado negou ser o dono do perfil "Menor Honda", e pode ter sido vítima da criação de perfil falso (fls. 586/602).

Josevaldo Ferreira da Silva requereu sua absolvição pelos seguintes fundamentos: a) o depoimento prestado por Kayo em 17/5/2022, quando ainda estava no hospital, foi realizado sob efeito de analgésicos, insuficiente para o reconhecimento da autoria delitiva; b) não há provas de estabilidade e permanência necessários à condenação pelo crime do art. 288 do CP; c) não existem provas da participação do adolescente no crime de roubo, a afastar a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA (fls. 586/602).

Fernando Pereira dos Santos alegou que não há provas de sua participação no delito, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 611/622).

Kayo Calado da Silva pugnou por sua absolvição nos seguintes termos: a) não preenchidos os requisitos do art. 288 do CP; b) não há como afiançar a participação do adolescente no delito, o que afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores; c) sobre o roubo, confessou que estava no local dos fatos, embora negue a existência de ajuste prévio, já que o crime teria sido planejado apenas por Cleber (fls. 632/638).

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades a enfrentar. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de roubo está tipificado no art. 157 do CP: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"; de acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. "É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Segundo o STJ (AgRg no HC 561498): "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese" - grifou-se.

Na hipótese, ouvida em juízo, a vítima, policial civil, disse que os fatos ocorreram quando voltava do trabalho (Jundiaí/SP); em uma avenida próxima a sua casa passou por várias motos (contou cinco); percebeu que quando foi visto, os

motociclistas retornaram e vieram em seu encalço; entrou na Rua Francisco Biasi; cercaram em três motos e anunciaram assalto; mandaram descer; "perdeu, desce da moto"; desembarcou e percebeu que um deles estava com arma na cintura; jogou-se para trás, sentado, sacou sua arma e efetuou o primeiro disparo; levantou e continuou efetuando disparos; foi até pessoa caída, identificou-se como policial e chamou socorro; depois descobriu-se que um dos assaltantes estava com moto deitado no final da rua; não presenciou quem estava com a arma de fogo; não procedeu ao reconhecimento; além dos dois (hospitalizado e falecido), os demais estavam de capacete, sem possibilidade de analisar sua feição; não foi chamado para reconhecer; vídeo não foi apresentado por si, polícia que obteve.

Além do relato acima transcrito, Rafael Diorio Costa, delegado de polícia, informou que no local dos fatos a vítima relatou que aproximadamente cinco ou seis pessoas tentaram abordá-lo e anunciaram o roubo, mencionado estarem armados; houve disparos; durante o socorro, um dos autores faleceu; Kayo permaneceu internado; iniciaram investigações para encontrar os demais envolvidos; ouviram preliminarmente Kayo, que passou informações sobre os demais autores; efetuada a prisão temporária de um [Warley], e em sua casa encontradas duas motos com numeração raspada, uma delas produto de roubo; também localizado Allyson, que compareceu com a genitora na delegacia e esclareceu dinâmica do roubo; Kayo posteriormente confirmou versão do adolescente; encontrada arma de fogo próximo ao local; era de conhecimento da Polícia Civil (Jundiaí e Francisco Morato) que agiam em conjunto principalmente na prática de roubo de motocicletas, versão confirmada por Allysson; durante a investigação verificou-se que se manifestavam muito nas redes sociais, ostentando armas de fogo e motos roubadas; no velório de Davi, atearam fogo em uma das motos roubadas, fato amplamente divulgado nas redes sociais; função de Erick era ficar na retaguarda; carro que constou na filmagem: em diligências verificou que de morador, sem interesse para a investigação; imagens recolhidas de residência vizinha.

Edilson Rogério de Moura informou que houve vários roubos de motocicleta na região de Campo Limpo Paulista; policial Flávio (vítima) percebeu aproximação estranha e quando entrou na rua da casa, notou seis pessoas, e uma ou duas com arma de fogo; reagiu; Davi faleceu; Kayo, mesmo alvejado, conseguiu descer a rua, e perdeu o controle da motocicleta, caindo em rua sem saída; aguardaram chegada da perícia; delegado corregedor e delegado da DIG presentes no local; encontraram revólver .38 a quatro/cinco metros de distância do local; no dia seguinte realizaram investigações, observaram mensagens de consternação nas redes sociais [pela morte de Cleber]; pessoa de Victor vendeu uma motocicleta a Davi, sob condição de honrar prestações, mas não o fez; informou a participação de Allysson no delito; motocicleta roubada em Jarinu incendiada por Erick; foi com o delegado ao hospital conversar com Kayo: disse que convidado por Allysson e Davi, e presentes Erick, Valdo e Warley; na casa de Warley encontraram duas motocicletas com numeração suprimida; disse saber quem era a sexta pessoa, vulgo Nando (Fernando); com relação a Josevaldo, recorda de pesquisas em redes sociais; informação de que era chefe da organização; na rede social se lembra de ter visto menção "eu não consigo me esquecer daquela cena" (consta no relatório e representação do delegado); com relação a Fernando, não se recorda das investigações nas redes sociais; com relação a Erick, informação de que consta em imagem da investigação, bem como informação de Kayo, que individualizou.

Nesse sentido, o delito está materializado pelo boletim de ocorrência (fls. 2/7), auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), auto de depósito (fl. 25), filmagem do ocorrido certificada às fls. 55/56, relatório final (fls. 75/76), auto de exibição e apreensão (fl. 175), relatório de diligências preliminares (fls. 180/181), relatório de investigações (fls. 184/187), relatório complementar (fls. 194/200), laudo pericial da arma de fogo (fls. 300/305), laudo do local dos fatos (fls. 308/320), processo n. 1500321-38.2022.8.26.0115 (relacionado ao pedido de prisão temporária, apenso a estes autos), e depoimentos produzidos em sede policial e judicial.

Passa-se a analisar a autoria delitiva.

À exceção de Josevaldo, revel, os demais acusados foram ouvidos em juízo.

Kayo Calado da Silva narrou que no dia 12 trabalhou; estava fazendo entrega em loja de roupa; chegou em casa por volta das 17h; Davi mandou mensagem convidando para andarem de moto; se encontraram na casa de sua avó; saíram para "dar pião" de moto; em uma tabacaria, Davi encontrou alguns colegas; fumaram narguilé; disse que iria embora; foram embora; parou em posto para abastecer moto; Davi brincou dizendo "bora fazer um arrastão", dando risada; levou na brincadeira e disse "bora"; saíram do posto; passaram em avenida; passou uma moto; Davi estava na frente de todos, virou a moto no meio da avenida e voltou; gritou: "volta, volta"; viraram a moto, ele virou rua à esquerda, desceu 200/300 metros e parou ao lado de moto [da vítima]; gritou: "perdeu"; vítima se jogou para o lado e gritou "polícia"; Davizinho correu e depoente também; ouviu disparos, ligou a moto e saiu de trás do carro; recebeu dois disparos (joelho, cotovelo e raspão na mão esquerda); à frente tentou acelerar moto, mas sem força no braço; rua sem saída, não conseguiu frear moto, reduziu para primeira marcha e se jogou ao chão, se não caíria em barranco; quando se jogou da moto, foi até portão e pediu socorro; pessoa atendeu, perguntou o que havia ocorrido; foi socorrido por ambulância; estavam juntos: Davi, "Zoio" e "menor"; os outros dois não conhecia (6 pessoas); não viu arma de fogo; na hora que Davi parou do lado do policial, apenas gritou "perdeu"; tem 18 (dezoito) anos (sem passagem); Erick não estava no dia dos fatos; estavam em 4 (quatro) motos (menor, "Davizinho", depoente e quarta pessoa, que não conhece); na garupa do depoente estava o "Zoio"; na do "menor" estava pessoa que não conhece; não se lembra muita coisa do que disse no hospital; no CDP também estava sob uso de medicamentos; não foi agredido, salvo quando ambulância o socorreu (no caminho para hospital); com relação a reconhecimento fotográfico, não fez, apenas de Allysson; policial mostrou a foto e reconheceu; no CDP não apresentaram foto; policiais não perguntaram se tinha condições de depor (em razão dos medicamentos); "Zoio": moreno, cerca de 1,60/1,70; não sofreu pressão para citar nomes; ninguém portava arma de fogo; saiu com Davi da tabacaria; no posto encostaram outras duas motos; não houve combinação; moto em nome do tio.

Erick Henrique Vieira Silva negou a prática do roubo; no dia estava trabalhando; trabalha com o pai em Itaquera; saía do trabalho às 18h30; chegou em casa cerca de 20h/20h10; conhece Kayo (da igreja) e Davi (mora na rua da casa); não tem antecedentes; 18 (dezoito) anos; não se intitulava "menor honda"; se reconhece na foto fl. 8, na esquerda não; direita com Davi; não publicou foto; foto esquerda fl. 9 - reconhece, mas não publicou; foi no velório de Davi; amigo chamou; havia diversas motos no local; acredita que policiais acharam que por estar no cemitério pudesse estar envolvido no crime.

Fernando Pereira dos Santos permaneceu em silêncio; informou que não conhecia acusados; no dia dos fatos ficou na casa da mãe.

Nada obstante as versões apresentadas pelos acusados, as provas são robustas no sentido de sua participação no roubo em questão, e suficientes para a prolação do decreto condenatório.

Inverossímil o relatado por Kayo de que assentiu ao chamado de Davi para "fazer um arrastão" acreditando se tratar de brincadeira. Sua conduta posterior - de segui-lo, inclusive após aquele ter ido em direção à vítima - denota que sabia da intenção de Davi, e a ela aderiu visando subtrair a motocicleta conduzida pelo ofendido.

Em reforço, nas duas oportunidades que ouvido na fase policial, afirmou que tencionava roubar a motocicleta (fls. 74, prestado em 17/5/2022, e fls. 109/110, prestado em 28/5/2022):

Nas duas oportunidades em que ouvido pelos agentes públicos (aos 17 e 28/5/2022), Kayo não apenas afirmou que efetivamente participou do delito, como indicou todos os coautores.

Por sua vez, em juízo, além de atenuar sua participação - ao afirmar que acreditava

se tratar de brincadeira por parte de Davi - isentou os demais acusados por si anteriormente delatados. Ainda, informa que estava sob efeito de medicamentos, o que em tese pode ter prejudicado seu relato, mesmo afirmando que não sofreu qualquer pressão dos agentes para citar nomes, em inegável contradição. A genitora de Allysson, ouvida em juízo, confirmou que esteve com o filho e acompanhou seu depoimento na delegacia de polícia, o qual consta às fls. 113/114 dos autos, e corrobora a tese acusatória:

O relato do adolescente, acompanhado de sua genitora, está em consonância com o da vítima - no sentido de que ao ser avistado pelos motociclistas, estes deram a volta e passaram a persegui-lo - e com o de Kayo - quanto à participação dos corréus na empreitada.

A versão exculpatória de Erick não é amparada por quaisquer provas, consignando que o próprio acusado se reconheceu nas fotos de fls. 8 e 9 dos autos apensos (1500321-38.2022.8.26.0115), certo que na foto da fl. 8 estava ao lado de Davi:

Todos os indícios permitem concluir que seja o dono do perfil "Menor Honda", conforme detalhada apuração da Polícia Civil, inclusive com apresentação de filmagem realizada no velório de Davi (fl. 10 dos autos n. 1500321-38.2022.8.26.0115), que o acusado afirmou ter comparecido.

O acusado se reconheceu na fotografia da fl. 9 do processo n. 1500321-38.2022.8.26.0115, em que está na condução, justamente, de uma motocicleta Honda, sem deixar margem de dúvidas sobre sua participação no delito:

Com relação a Josevaldo e Fernando, todas as provas acima analisadas dão conta da sua participação, destacando-se os depoimentos extrajudiciais de Kayo e Allyson, que os inseriu no local dos fatos na condição de coautores, reforçados pelas diligências constantes da representação pela prisão temporária (fls. 1/17 dos autos n. 1500321-38.2022.8.26.0115), ressaltando, quanto a Fernando, que embora não decretada sua prisão preventiva, em uma análise mais acurada das provas, especialmente o segundo depoimento de Kayo (fls. 109/110) e o depoimento de Allyson (fls. 113/114), é possível afirmar, com a segurança necessária, que também participou do delito, sendo imprestável o depoimento de Natalia para atestar sua inocência, dado seu evidente interesse na causa.

Sobre a tese defensiva invocada por Erick de que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado por Kayo não observou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CP, deve ser ponderado que o corréu nominou os demais partícipes e descreveu a dinâmica do crime, com destaque às participações de cada acusado, o que também se extrai do relato de Allyson.

Assim, a condenação é mandatória, nos exatos termos da denúncia.

O emprego de arma de fogo restou evidenciado pelo depoimento da vítima, dos policiais ouvidos em juízo e do laudo pericial de fls. 300/305, realizado sobre a arma apreendida nas proximidades do local. Com relação ao concurso de agentes, igualmente inquestionável e extraído do relato da vítima, dos agentes, de Kayo (em ambas as fases), da genitora de Allyson e do adolescente (fls. 113/114).

Quanto ao delito do art. 244-B do ECA, cuida-se de crime formal, conforme extraído da súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Logo, basta a prática/indução à prática de crime com menor de 18 (dezoito) anos, o que restou evidenciado no caderno processual, conforme extraído do relato do adolescente Allyson (fls. 113/114), que confessou ter participado do roubo com os corréus, maiores, certo que Kayo, em seu interrogatório, atestou a presença do "menor" no momento do delito, em reforço à tese acusatória, impondo-se a

condenação.

Anota-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal" (STJ, HC 613196/SP).

Todavia, deve ser ressaltado que os delitos de roubo e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, já que mediante ação única os acusados praticaram ambos. Neste norte: "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020)- grifou-se.

Ainda: "O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal" (STJ, HC 636025/RJ).

Por fim, o art. 288 do CP criminaliza a conduta de "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes".

Em comentário ao referido crime, Nelson Hungria (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal, v. IX, p. 177) destacava que: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial" - grifou-se.

Imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência: "para a caracterização do delito de formação de quadrilha são necessários o concurso de pelo menos quatro pessoas, a finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos, bem como exige-se a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não se verifica no caso vertente" (STJ, REsp 1054460/SP).

Consequentemente, inviável sejam tais requisitos presumidos: "AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) - grifou-se.

Na hipótese, dos relatos de Kayo e Allysson é possível concluir que o ajuste para a prática de roubos se resumiu ao dia dos fatos, tanto que anteriormente - segundo Allysson -, Erick já havia roubado uma moto, e juntos rumaram a Campo Limpo Paulista, ocasião em que ocorreu o roubo tentado objeto deste processo.

Apesar do relato dos policiais em juízo de que há informações de que os acusados estão envolvidos na prática de roubos, não há prova segura que ateste sua vinculação estável, e nem da prática de roubos pretéritos, à exceção da motocicleta de Jarinu, ocorrida no dia dos fatos e informada pelo adolescente em seu relato de fls. 113/114.

Desta forma, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP a absolvição é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, o concurso de agentes e utilização de arma de fogo constituem causas de aumento específicas do crime de roubo, que não devem ser consideradas na primeira fase, sob pena de bis in idem.

No mais, embora a vítima seja policial civil, o que constitui fundamento apto à exasperação da pena-base, inviável na hipótese, já que não há qualquer indício de

que os acusados conhecessem tal circunstância, ao contrário, caso soubessem possivelmente não teriam investido contra seu patrimônio.

Para o delito do art. 244-B do ECA, a despeito de a corrupção do adolescente ter sido levada a efeito para a prática de roubo circunstanciado, referida circunstância está enquadrada na causa de aumento do § 2º.

Assim, ambas as penas-base são fixadas no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não excedem a gravidade inerente aos tipos abstratos.

Na segunda fase, presentes as atenuantes do art. 65, I, do CP para Kayo, Erick e Josevaldo, menores de 21 (vinte e um) anos. Ainda, presente a atenuante da confissão para Kayo (art. 65, III, "d", do CP). Todavia, diante da vedação da súmula 231 do STJ, inviável a redução das penas aquém do mínimo legal, para ambos os delitos.

Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, presentes as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

O STJ, na súmula 443, assentou que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Desta forma, de rigor o acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pela utilização da arma de fogo, esta prevista em parágrafo específico do art. 157 (§ 2º-A, I) e aplicável cumulativamente.

Chancelando a possibilidade de soma dos acréscimos das circunstâncias do § 2º e § 2º-A: "[...] na derradeira etapa, penas dos roubos majoradas em 1/3 pela majorante do concurso de agentes e mais 2/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Entendimento que não se revela ilegal [...]" (TJSP; Revisão Criminal 0043188-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)".

Assim, as penas são aumentadas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa de reclusão, com a incidência da circunstância do art. 157, § 2º, II, do CP. Aplicada a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP as penas vão para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Por fim, considerando que o delito foi praticado na modalidade tentada (art. 14, II, do CP), e que anunciado o roubo à vítima (conforme relatos da própria vítima, de Kayo – em ambas as fases – e de Allysson), não tendo sido consumado em razão de sua pronta reação, as penas devem ser decrescidas na fração mínima de 1/3, definitivamente fixadas em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

No tocante ao crime do art. 244-B do ECA, incide a causa de aumento do § 2º do mencionado artigo, já que a corrupção do adolescente visou à prática de crime hediondo (art. 1º, II, da Lei n. 8.072/1990), crescendo-se 1/3 às reprimendas, definitivamente fixadas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso formal heterogêneo, e aplicada a regra do art. 70, primeira parte, do CP, cresce-se 1/6 à pena mais grave (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, todos do CP), fixadas as penas definitivas em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, bem como 16 (dezesseis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, uma vez que os delitos foram praticado em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo, cabível a fixação do regime fechado para cumprimento das penas para todos os acusados, com fixação do valor unitário do dia-multa do mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Não preenchidos os requisitos objetivos dos arts. 44 e 77 do CP, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para, nos termos da fundamentação, CONDENAR os réus KAYO CALADO DA SILVA, ERICK HENRIQUE VIEIRA SILVA, FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA como incurso no delito do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, na forma do art. 14, II, ambos do CP, em concurso formal com o crime do art. 244-B, § 2º, do ECA às penas de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridas

em regime inicial fechado, e 16 (dezesesseis) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP), bem como ABSOLVÊ-LOS da imputação do art. 288 do CP nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Mantidos os fundamentos da decisão de fls. 226/229, aos quais se acresce a presente condenação, de rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados, sendo o caso de decretá-la com relação ao réu Fernando Pereira dos Santos, nos exatos termos da fundamentação mencionada, sob pena, inclusive, de manter situação contraditória com os demais. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o para cumprimento.

Comunique-se o ofendido sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida, se o caso.

Custas pelos acusados na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-os para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA